



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 78/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

בפני כב' המפקחת אסתי שחל

בעניין:

1. חיים אייזנר
אורנה אייזנר
 2. דורון ברון
שרה ברון
 3. יאיר סטבסקי
חנה סטבסקי
 4. שרון בר
רונית בר
 5. שריאל אברמוביץ
 6. מרדכי אמסילי
דינה אמסילי
 7. נטליה זילברמן
פיוטר זילברמן
 8. אלה לטובסקי
 9. אבי זוהרי
נעמה זוהרי
 10. חלי יולדוס
 11. דהן יונתן ניסים
 12. הלנה סקר
יעקב סקר
- ע"י ב"כ עו"ד עידן מרדכי ואח'
רח' מחניים 4, חיפה
טל': 04-8381113, פקס': 04-8381115

התובעים

- נ ג ד -

1. ישראל ישראלי
2. מרגלית ישראלי
ע"י ב"כ עו"ד משה לוי
- רח' הרב קוק 95, הרצליה, 46505
3. כדורי ג'מיל
ע"י מרים רובנישטיין ת.ז. 050695196
רח' כיבוש העבודה 25, הרצליה

הנתבעים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 78/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

פסק דין

1. עניין לנו בתביעה לפי סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתיים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח – 2008 (להלן: "חוק החיזוק").
2. התובעים הם בעלים של 12 מתוך 14 דירות מגורים המצויות בבית המשותף אשר ברחוב כיבוש העבודה 25 בהרצלייה הידוע כגוש 6536 חלקה 523 (להלן: "הבית").
3. הנתבעים 1 ו- 2 רשומים כבעלים של חלקת משנה 3 בבית. הנתבע 3, כדורי ג'מיל רשום כבעלים של חלקת משנה 2 בבית. על פי טענת הגב' מרים רובינשטיין, אשר לא הוכחה, כדורי ג'מיל נפטר והיא יורשת זכויותיו בחלקת משנה 2 ומחזיקה בה. ואולם, זכויותיה אלה טרם נרשמו בלשכת הרישום.
4. במסגרת התביעה, מבקשים התובעים בהתאם לחוק החיזוק לאשר להם, חרף התנגדות הנתבעים, ביצוע עבודות ברכוש המשותף, הכוללות עבודות לחיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה לפי תכנית המתאר הארצית 38 (להלן: "תמ"א 38") בהתאם להסכם שנחתם בינם ובין היזם, איל ברקוביץ, ביום 1.6.10 לביצוע עבודות אלה (להלן: "ההסכם"), ובהתאם לבקשה להיתר בנייה שהוגשה על ידם לוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצלייה (הוגשה וסומנה נ'1) (להלן: "התוכנית").
5. על פי ההסכם והתכנית מתוכננות בבית העבודות הבאות: חיזוק הבית מפני רעידות אדמה ושיפוצו, התקנת מעלית, תוספת קומה הכוללת 4 דירות חדשות עם חדרי יציאה לגג, כשלכל אחת מהן מרפסת וממ"ד, תוספת דירה בקומת הקרקע הכוללת ממ"ד, יצירת מקומות חנייה לדירות הקיימות ולדירות החדשות.
6. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה דנה בהתנגדויות שהוגשו כנגד התוכנית על ידי הנתבעים והחליטה בהחלטתה מיום 29.2.12 לדחותן, והתוכנית אושרה בתנאים. ערר שהוגש על ידי הנתבעים לוועדת הערר נדחה אף הוא בהחלטת ועדת הערר המחוזית מיום 12.7.12.
7. לטענת התובעים הם זכאים לאכוף על הנתבעים את ביצוע עבודות החיזוק בהתאם להוראות חוק החיזוק.
8. הנתבעים 1 ו- 2 טענו בכתב ההגנה, בתמצית, כדלקמן: התביעה אינה עומדת בדרישות הסף שנקבעו בחוק החיזוק, ומשכך דינה להימחק על הסף; היזם פעל שלא בתום לב ובחוסר שוויון בין בעלי הדירות באופן בו התובעים או חלק מהם קיבלו או אמורים לקבל במרמה תמורה נוספת מעבר למה שהוסכם בהסכם שנחתם עם היזם; לדירות החדשות מתוכנן להיבנות מרחב דירתי מוגן בשטח של 12.5 מ"ר לכל דירה, בעוד שלדירות הקיימות לא מתוכנן מרחב דירתי לכל דירה והן תמשכנה לעשות שימוש במקלט המשותף אשר הוקטן אף הוא בתוכנית לצורך בניית פיר מעלית; זכויות הבניה נמכרו ליזם ב"נזיד עדשים" שכן התמורה המתקבלת בעבור זכויות אלה מכוח ההסכם נמוכה באופן שאינו סביר; השוואה בין תוכנית זו לתוכניות אחרות שהוגשו בהרצלייה ובערים אחרות מלמדת כי התמורה נמוכה במיוחד שכן בתוכניות האחרות מקבלים בעלי הדירות ממ"דים ומרפסות לדירות הקיימות וזאת בנוסף על חיזוק הבית מפני רעידות אדמה ומעלית; עיקר התמורה מתבטאת בשדרוג ערך הדירות בקומות העליונות שקיבלו תוספת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 78/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

של מעלית אשר אינה מקנה יתרון לדירת הנתבעים 1 ו-2 המצויה בקומה הראשונה, ומשכך יש צורך בעריכת טבלת איזון בטרם תאושר התוכנית.

9. הגב' רובינשטיין טענה בכתב ההגנה בתמצית כדלקמן: טרם ניתן היתר לביצוע עבודות החיזוק ומשכך דין התביעה להימחק על הסף; הצבת חדר האשפה, והחניות בהתאם לתוכנית מהווה פגיעה בזכותה הקניינית, פוגעת באיכות החיים, ומורידה את ערך דירתה; התובעים והיזם פועלים בחוסר שקיפות ובחוסר תום לב.

דיון והכרעה

המסגרת הנורמטיבית

10. במסגרת ההיערכות הכוללת של מדינת ישראל מפני רעידות אדמה, התקבלה ביום ט"ז באדר ב' התשס"ה (27 במרץ 2005) החלטת ממשלה המאשרת את תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים שהוצא היתר לבנייתם קודם ה-1 בינואר 1980, מפני רעידות אדמה – תמ"א 38 (להלן: "תמ"א 38" או "התוכנית"). על מטרת התוכנית ניתן ללמוד מהדברים שנאמרו בסעיף 2 לדברי ההסבר לה:

"מבנים חדשים חייבים לעמוד בתקן 413 לשם עמידותם בפני רעידות אדמה. תמ"א 38 נועדה לאפשר חיזוק מבנים קיימים שלא נבנו על פי התקן על מנת לשפר עמידותם בפני רעידות אדמה. הוראות התמ"א קובעות את המסגרת הסטטוטורית שתאפשר מתן היתרי בנייה מכוחה, וכן מציעה תמריצים שיעודדו את החיזוק ויאפשרו אותו מבחינה כלכלית. זאת מתוך שמירה על איזון בין הצורך ומימונו ובין שיקולים עירוניים רחבים אחרים".

11. על מנת לעודד חיזוקם של המבנים מציעה התוכנית תמריצים שונים. ראה סעיף 4 לדברי ההסבר לתוכנית שכותרתו: "תמריצים לעידוד החיזוק":

"היזומה לחזק מבנה בפני רעידות אדמה וההתארגנות הדרושה לשם כך מצויה בידי בעליו. התוכנית מציעה תמריצים לעידוד ביצוע החיזוק במבנים אך אינה יכולה לכפות אותו..... במסגרת תמריצים לביצוע החיזוק, מציעה התמ"א תוספות בניה וכאמור מאפשרת מימוש התוספות המוצעות בה, בהליך ישיר למתן היתרי בנייה מכוחה.... ללא צורך בהכנת תוכנית מפורטת קודם למתן ההיתר....".

12. חוק החיזוק נועד ליצור מנגנון שיאפשר לממש תוכניות חיזוק לפי תמ"א 38 תוך יצירת איזון בין מעמדו של הרכוש המשותף וזכויות בעלי הדירות בבית המשותף מצד אחד לבין הצורך הציבורי החשוב שבחיזוק בתים משותפים לשיפור עמידותם מפני רעידות אדמה. על מטרת החוק ניתן ללמוד מדברי ההסבר לו:

"מטרתו העיקרית של התיקון המוצע בהצעת חוק זו היא להוריד את רף ההסכמה הדרוש על פי חוק המקרקעין לשם ביצוע עבודה ברכוש המשותף, בנכס שהוא בית משותף..... בכך מבקשת הצעת החוק ליצור מנגנונים אשר יקלו על ניצול זכויות בניה וביצוע עבודה ברכוש משותף הנעשים במסגרת תכנית החיזוק, תוך יצירת איזון בין מעמדו של הרכוש המשותף וזכויות בעלי הדירות בבית המשותף מצד אחד, לבין הצורך הציבורי החשוב שבחיזוק בתים משותפים לשיפור עמידותם מפני רעידות אדמה".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 78/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

13. חוק החיזוק קבע כללים משפטיים לביצוע עבודות ברכוש המשותף לפי תמ"א 38, ובין אלו נכללו עבודות שמטרתן שינוי ברכוש המשותף (סעיף 3 לחוק החיזוק), עבודות שמטרתן הרחבת דירה (סעיף 4 לחוק החיזוק), עבודות שמטרתן בניית דירה חדשה (סעיף 5 לחוק החיזוק) ועבודות שמטרתן הריסת בית קיים והקמתו מחדש (סעיף 5א לחוק החיזוק). החוק יצר מנגנון לפיו למפקח על רישום מקרקעין הסמכות ליתן הסכמה לביצוע העבודות חרף סירוב חלק מבין בעלי הדירות.

14. בע"א (חי') 899-03-09 שרה קלצ'וק נ' צבי אורון (פורסם בנבו) - להלן: "קלצ'וק", הדן בחוק החיזוק, מאמץ כב' השופט כהן את גישת כב' השופט חשין בפסק הדין ברע"א 7112/92, בתיה צודלר נ' שרה יוסף, פ"ד מח(5) 550 באשר לתפיסת הקניין בבית משותף וקובע כי ביישום "חוק החיזוק" יש צורך להפעיל הגנות שונות מאלה הנהוגות על פי התפיסה הכללית בדיני הקניין, ובמקום הגנה קניינית המאפשרת למיעוט למנוע את ביצוע העבודות, יש צורך להפעיל את "הגנת החבות" בלבד, דהיינו סעד שיותר בידיו פיצויים אם לאחר ביצוע פעולות החיזוק יתברר שנגרם לו נזק:

"חוק החיזוק" יצר משטר מיוחד, ועל כן, בבואנו ליישם את "חוק החיזוק" עלינו לבחון את זכויות מזויות מבט שונה מהזויות הרגילה בה אנו רגילים לנתח זכויות של קנייניות של בעלי דירות בבית משותף.... המחוקק ייחס לעבודות המתבצעות לפי "חוק החיזוק" חשיבות ומשקל גדולים יותר מחשיבות זכויותיו של מיעוט בעלי הדירות בבית המשותף, ומשקלן להתנגד לעבודות אלה". (פסקה 12 לפסק הדין).

"על כן ולהשקפתי בבואנו ליישם את "חוק החיזוק" עלינו לשנות מהתפיסה הרגילה המנחה אותנו בהגנת זכויותיהם הקנייניות של בעלי דירות ברכוש המשותף, ובמקום לנהוג על פי תפיסת ההגנה הכללית בדיני המקרקעין עלינו לאמץ את התפיסה שעמדה בבסיס פס"ד צודלר". (פסקה 17 לפסק הדין).

15. כב' השופט כהן מאמץ בפסק הדין בעניין קלצ'וק את מבחני סבירות קבלת ההחלטה הנכפית על המיעוט גם בהקשר לחוק החיזוק:

"כאשר יינתן היתר בנייה (תנאי להגשת תביעה לפי חוק החיזוק עוד טרם התיקון), יתייצב נא הרוב בפני המפקח על רישום המקרקעין, והמפקח יבחן האם הופר השוויון, והאם הרוב נוהג בתום לב, והאם "פיחותים" בזכויות הקניין של המיעוט בטלים בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מעבודות החיזוק הנעשות בבית. מעל לכל, אם ימצא המפקח מקום לכך, יהיה בוודאי מוסמך להתנות את ביצוע העבודות בפיצוי כספי. המפקח על רישום המקרקעין לא יהיה רשאי למנוע את ביצוע העבודות רק על בסיס טענות המיעוט בנוגע לפגיעה בזכויות הקניין שלו. זכויות מעין אלה תדללנה ויגרמו "פיחותים", אך פגיעות אלה לא יהיה בכוחם למנוע את עבודות החיזוק. סמכות ההתערבות של המפקח, לקבל את טענות המיעוט, ולא לאשר את ביצוע עבודות החיזוק, תהיה אפוא מצומצמת ביותר".

ובהמשך:

"אם יפעל היזם בשוויון בין בעלי הדירות בבית, ויפעל בתום לב, ויחשב את חישוביו לפי הנוסחאות הקבועות בסעיף 5 ל"חוק החיזוק", זכויות הקניין של המיעוט לא תוכלנה לגבור על



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 78/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

הזכויות הקנייניות של הרוב, ולמפקח על רישום המקרקעין לא תהיה עילה לדחות בקשתו של הרוב לכפות על המיעוט את ביצוע עבודות החיזוק ובניית הדירות הנוספות לשלם מימון עבודות החיזוק, חרף הפגיעה הנגרמת".

פסק הדין אושר בפסק דינו של כבוד השופט רובנישטיין ברע"א 4138/10, קלצ'וק שרה נ' צבי אורון (פורסם בנבו).

16. נבחן להלן את טענות הצדדים בהתאם לפסיקה הנ"ל.

האם התקיימו תנאי הסף להגשת התביעה

17. סעיף 2 לחוק החיזוק מורה כדלקמן:

"(א) ניתן היתר בנייה לביצוע עבודה ברכוש משותף, על פי תכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה – עבודה ברכוש המשותף), יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה. (ב) הוראות לפי חוק המקרקעין ימשיכו לחול על עבודה ברכוש המשותף, ככל שאינן סותרות את ההוראות לפי חוק זה".

"היתר בניה" מוגדר בסעיף 1 לחוק החיזוק כדלקמן: "היתר לפי חוק התכנון והבנייה או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים".

"החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" מוגדרת בסעיף 1 לחוק החיזוק כדלקמן:

"החלטה בדבר אישור בקשה להיתר בתנאים, שהתקבלה במוסד תכנון, לאחר שהתקיימו כל אלה: (1). מוסד התכנון מצא כי הבקשה תואמת לתכנית החיזוק וכן לתכניות תקפות אחרות ולתכניות מופקדות, ולתנאים לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965 (להלן: "חוק התכנון והבנייה") ככל שנקבעו; (2) מוסד התכנון מצא כי הבנייה המבוקשת משתלבת במערכות התשתית הקיימות והמתוכננות בסביבתה; (3) הוגשו התנגדויות לבקשה להיתר לפי הוראות חוק התכנון והבנייה - מוסד התכנון החליט בהן;

ביום 9.8.12 הוגש מסמך מאת האדריכלית אניטה שטיבלמן מיום 8.8.12 מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה- הרצליה (להלן: "הוועדה"), בו אושר כי ביום 29.12.12 ניתנה החלטת הוועדה (ההחלטה צורפה כנספח לכתב התביעה) העונה "על דרישות סעיפים (1) – (3) של הגדרת "החלטה לאשר בקשה בתנאים" בחוק החיזוק".

משכך, שוכנעתי כי דרישות הסף לתחולת חוק החיזוק התקיימו, התובעים זכאים להיכנס בשעריו של חוק החיזוק וקיימת בידי הסמכות לדון בתביעה.

האם יש בעבודות כדי לפגוע בזכויותיהם הקנייניות של הנתבעים?

18. בהתאם לנסח הרישום של הבית, לכל אחת מהדירות הקיימות צמודה חניה ובסך הכל בית 14 חניות צמודות. לדירת הנתבע 3 צמודה חניה המסומנת בתשריט הבית המשותף באות ז'. התוכנית, נושא ההליך, מדגימה 20 חניות. השוואה בין תשריט הבית המשותף לתוכנית מלמדת כי מיקום החניה הצמודה לדירתו של הנתבע 3 שונה מזה המודגם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 78/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בתוכנית. היינו, במסגרת התוכנית הוסטה החניה הצמודה לדירת הנתבע 3 למיקום חדש.

19. חוק החיזוק חל על ביצוע עבודות **ברכוש המשותף** לצורך ביצוע פרויקט תמ"א 38, ואינו מאפשר ביצוע עבודות ברכושו הפרטי של בעל דירה או נטילת חלק ממנו לצורך הבניה (ראה סעיף 2 לחוק החיזוק). חוק החיזוק אינו מתיר למפקח על רישום מקרקעין לאכוף על בעל דירה לבצע עבודות בקניינו הפרטי או לשנותו. במקרה דנן התוכנית משנה את מיקום החניה שבבעלותו של הנתבע 3, ומצריכה ביצוע עבודות בחניתו הפרטית, ללא שניתנה לכך הסכמתו. אישור התוכנית, כפי שהיא, משמעותה פגיעה בזכותו הקניינית של הנתבע 3. משכך, ובהעדר הסכמת הנתבע 3 לביצוע העבודות בחניה הצמודה לדירתו, או לשינוי תוואי החניה, לא ניתן לאשר את התוכנית כפי שהיא.

20. בעדותו טען מר בן נעים מטעם התובעים כי לא קיימת פגיעה בנתבע 3 מהטעם שבפועל לא ניתן להחנות הרכבים בשטח שהוקצה לכך בתשריט הבית המשותף, וכי התוכנית מסדירה עניין זה (פרוטוקול מיום 31.12.12, עמ' 6, שורות 16-17). טענה זו לא נטענה בכתבי בי דין של התובעים, ולא הוכחה. מכל מקום אף לו הייתה מוכחת לא היה בה כדי להועיל נוכח העובדה כי זכותו של הנתבע 3 בחניה היא זכות קניינית רשומה, וגם אם אינה באה לידי ביטוי בשטח, לא ניתן לשנותה אלא בהסכמתו, וזו, כאמור לא ניתנה.

21. נוכח האמור לעיל, אני מוצאת כי יש בתוכנית משום פגיעה בזכותו הקניינית של נתבע 3 בעטייה של החלפת חניה הצמודה לדירתו באחרת ללא שניתנה לכך הסכמתו, ומשכך, לא ניתן לאשר את ביצוע העבודות בהתאם לתוכנית.

22. בנוסף, מר בן נעים העיד כי חלק משטח מקלט הבית נגרע לטובת בניית המעלית, ולכן שטחו של המקלט כפי שהוא מודגם בתכנית קטן מכפי שהוא בפועל. אולם, מאחר, וכפי שעלה מעדות זו, הג"א אינה מאשרת את הקטנת שטח המקלט, פעלו התובעים להכנת תכנית נוספת המגדילה את שטחו של המקלט (סעיף 39 לתצהירו). בנסיבות אלה, נראה כי התוכנית (נ"1) אינה מדגימה את שטח המקלט הנדרש, ויש ממילא צורך בהגשת תכנית מעודכנת/מתוקנת, ואף מטעם זה אין בידי לאשר את ביצוע העבודות בהתאם לתוכנית שבפני.

23. משמצאתי כי אין בידי לאשר את התוכנית כאמור לעיל, אין מקום לקבל את התביעה. יחד עם זאת, ומאחר ויש להניח שתוגש תכנית מתוקנת אשר תדגים מקלט התואם את דרישות הג"א, ולא תפגע בחניה הצמודה לדירתו של הנתבע 3, אזי מצאתי להתייחס גם לכל יתר טענות ההגנה אשר הועלו בפני, וזאת על מנת שהצדדים לא יצטרכו להידרש אליהם מחדש, ככל שאכן תוגש תכנית מתוקנת.

חוסר שוויון וחוסר תום לב

24. בהתאם להסכם שחתמו התובעים עם היזם, בכל אחת מדירות התובעים תוכננה להיבנות מרפסת, ואולם, אין מחלוקת בין הצדדים כי התוכנית, בסופו של יום, אינה כוללת בניית מרפסות לדירות הקיימות אלא רק לדירות החדשות. אין גם מחלוקת כי התכנית וההסכם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 78/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

אינם כוללים בניית ממ"דים לדירות הקיימות אלא רק לדירות החדשות. אין גם מחלוקת כי לצורך בניית מעלית בבית נדרש היה להקטין את שטח המקלט הקיים בבית. לטענת הנתבעים הסכמת התובעים לכל האמור לעיל אינה מתקבלת על הדעת, נוכח התמורה הגבוהה אותה מקבל היזם בהתאם להסכם (זכויות בניה ל - 5 דירות חדשות), ויש בכך כדי להעיד על כך שהתובעים או חלק מהם קיבלו תמורה עודפת חסויה מעבר לתמורה עליה הוסכם בהסכם עם היזם. הנתבעים 1 ו- 2 מפנים לחוות דעת שמאית של הגב' מיכל בר פרו בה נטען כי ההפרש בין שווי הזכויות שנמכרו ליזם לבין שווי התמורה אותה מקבלים בעלי הדירות בבית בהתאם לתכנית עומדת על סך של 2,783,000 ₪ לטובת היזם. נבחן להלן, האם יש בטענות אלה כדי להוכיח חוסר שוויון ו/או חוסר תום לב:

25. עיון בהסכם מלמד כי הצדדים הסכימו כי העבודות כפופות "לאישורן על ידי רשויות התכנון" וכי "היה ומסיבה כלשהי לא יינתן היתר בניה להוספת מרפסת לכל דירה ו/או חלק מהדירות יקבל כל דייר כאמור פיצוי כספי בגובה 15,000 ₪ בגין אי בניית המרפסת (ראה עמ' 3 להסכם צורף כנספח לתצהירו של מר שי בן נעים מטעם התובעים).

26. מהראיות שהוצגו בפני עולה כי נעשה ניסיון לכלול בתוכנית בניית מרפסות לדירות הקיימות, ואולם נוכח סירובה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצלייה ירד עניין זה מן הפרק. ראה פרוטוקול ועדת הערר מיום 12.7.12 מפי אדר' אמיר בראשי עמ' 2, שורות 9-12:

"כאשר יש לנו בתים קיימים שהמרפסות שלהם המקוריות נסגרו ברבות השנים, והתווספו לשטח הדירות הקיימות. כתוצאה מכך הדירות הקיימות מקבלות חיזוק ולא מרפסות.... מרפסות שהיו פתוחות ונסגרו, הדירות האלה לא יכולות לקבל עוד תוספת של מרפסת".

27. הנה כי כן, התובעים לקחו בחשבון כי בניית המרפסות עשויה שלא לצאת אל הפועל, ואף יצרו מנגנון לפיצוי במקרה שכזה. מר שי בן נעים, נציג היזם, שהעיד מטעם התובעים, לא הכחיש בעדותו הראשית כי התובעים זכאים לפיצוי כספי בגין אי בניית המרפסות ועוד הוסיף כי "בכל מקרה תוכן תשתית קונסטרוקטיבית שתאפשר הוספת מרפסת זיזית, הוספת תריס חשמלי וחלון יציאה החוצה למרפסת ובאם תאושר התוכנית הר/2213 המהווה שדרוג עירוני להוראות תמ"א 38 וזאת עד לסיום בניית השלד, כי אז יפעל לבניית המרפסות". (סעיף 36 לתצהיר עדות ראשית של מר בן נעים אשר לא נסתר).

28. מהראיות שהוצגו בפני עולה כי לצורך בניית המעלית בחדר המדרגות של הבית נדרש היה לחדור לתוך דירתם של הנתבעים 1 ו-2 ולהקטין את שטח דירתם בכ - 1 מטר, על מנת שלא יהיה צורך להקטין את המקלט. בין היזם והנתבעים 1 ו-2 התנהל משא ומתן לקבלת פיצוי בשל האמור לעיל, אשר לא הבשיל. בנסיבות אלה, הוכנה התכנית (נ1) אשר במסגרתה הוקטן הן שטחו של המקלט והן שטחו של שלוש דירות (בבעלות התובעים 2, 7 ו- 12) לצורך בניית פיר המעלית על חשבון שטחים אלו.

29. כעולה מעדותו של מר בן נעים, אשר לא נסתרה, קיבל כל אחד מהתובעים שמדירתו נגרע שטח, כאמור, פיצוי כדלקמן (פרוטוקול מיום 31.12.12, עמ' 4, שורות 41-36 ועמ' 5 שורות 1-3):

"...היינו צריכים לבחון חלופה אחרת וזה גרר אותנו לשינוי והסטה של המעלית לתחום אותן שלוש דירות היה מדובר בשבירה של מטבחים, והם קיבלו יותר, העתקה של המטבח, הם קיבלו



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 78/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

מטבח והסיתו אותו. קיבלו מטבח, שיפוץ שמחזיר להם את אותה חתיכה בצד השני בהמשך של הדירה, בפיר של מסתור כביסה, וריצוף והעמדה של כל נזק שיגרם בבית. ש. הם קיבלו כסף ת. לא קיבלו כסף, אלא תמורה שווה בכסף. ש. למה הם קיבלו את זה בגלל שהקטינו להם את הדירות ת. כן כי אני מסית להם את המטבח אני שם להם מעלית במקום שטח פרטי".

30. לא מצאתי פסול בכך שבעלי הדירות שמשטחם בלבד נגרע שטח לצורך בניית פיר המעלית קיבלו פיצוי בגין כך, שעה שיתר בעלי הדירות שמשטחם לא נגרע דבר, לא יזכו בפיצוי זה. המדובר בגריעת זכויות קנייניות בלעדיות של כל אחד מבעלי דירות אלה, ואין כל פגם בכך שמתנהל בעניין זה משא ומתן עם כל אחד מבעלי הדירות בנפרד, אשר בסופו ניתנה להם תמורה חלף השטח אותו תרמו. איני סבורה כי פיצוי שכזה יש בו כדי להפר את השוויון בין בעלי הדירות.

31. נדמה כי הנתבעים מתייחסים לפרויקט כעסקה רגילה שמטרתה מקסום רווחים כלכליים. תימוכין לכך מצאתי בעדותו של הנתבע 1 ממנה התרשמתי כי לא חיזוק הבית עומד לנגד עיניו אלא מקסום רווחיו הכלכליים כתוצאה מהפרויקט. ראה פרוטוקול מיום 13.1.13, עמ' 30, שורות 16-20 :

"ש. אתה יודע בעצם מה הרעיון של תמא 38 ת. היום אני יודע, חיזוק של בניין הסתובבתי בהרצלייה וראיתי שכולם מקבלים ממדים ומרפסות ושאלנו לא מקבלים שום דבר לכן אני לא שותף לעסקה הזו. ש. חיזוק הבניין כנגד רעידות אדמה אתם מקבלים ת. אפשר לעשות גם ממדים שזה חיזוק נגד הטילים שזה יותר חשוב היום".

ראה גם את חוות דעת השמאית הגב' פרו הבוחנת את הפרויקט כעסקה כלכלית לכל דבר ועניין (צורפה כנספח לכתב ההגנה מטעם הנתבעים 1 ו-2).

32. אולם, הרציונל העומד בבסיסו של חוק החיזוק הוא לא מקסום רווחים אלא להביא לחיזוק בתים משותפים הזקוקים לכך מפני רעידות אדמה. אני מוצאת בהקשר זה לאמץ את קביעתו של חברי כב' המפקח אורן סילברמן בתיק 573/11, קופמן ואח' נ' שומרוני (לא פורסם) :

"מדינת ישראל ראתה בביצוע חיזוק כאמור כמטרה מרכזית וחשובה, לא לשם מימוש זכויות קנייניות, אלא לשם הצלת חיי אדם, לא רק של אלו הנמצאים בתוככי הבית אלא גם של אלו אשר נמצאים ברחוב, בסביבתם של אותם בתים העלולים לקרוס בשעת סכנה. לא ניתן גם להתעלם מכך שללא חיזוק תתיכן קריסה של עשרות אלפי בתים שמשמעותה הנוספת מעבר לאובדן חיי האדם המידי, סדר גודל של מאות אלפי אנשים מחוסרי בית ומחוסרי כל. הפתרון שמצאה המדינה להקלת אפשרות החיזוק היה על ידי מתן תמריצים תכנוניים (במסגרת תמ"א 38) והתאמת דיני המקרקעין לצורך ביצועם (חוק החיזוק). אולם, אלו הם רק תוצר לוואי ואין הם מהווים את העיקר במסגרת הליך של חיזוק".

33. לכן, טענתם של הנתבעים ולפיה בפרויקטים שנעשו בבתים אחרים מכוח תמ"א 38 קיבלו בעלי הדירות ממ"ד ומרפסת לכל דירה, הגם שלא הוכחה, אינה מהווה נימוק ראוי למניעת עבודות החיזוק. לדידי, משמתקיים התנאי לחיזוקו של הבית, הרי ש"התמריצים התכנוניים" הם תלויי משא ומתן בין בעלי הדירות לבין היזם בכפוף לעקרונות השוויון ותום הלב. הפועל היוצא הוא שבהחלט ייתכן שבבית אחד התמורה המתקבלת לבעלי הדירות תהא שונה מזו המתקבלת בבית אחר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 78/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

34. נוכח כל האמור לעיל, לא מצאתי כי בהסכמת התובעים להקטנת המקלט ולאי בניית המרפסות והממ"דים יש כדי להוכיח חוסר תום לב וחוסר שוויון, ואני דוחה את טענות הנתבעים בהקשר זה.

35. טענה נוספת שהועלתה ע"י הנתבע 1 היא כי היזם ניהל עמו משא ומתן בנפרד משאר בעלי הדירות, וביקש ממנו לשמור על חסיון מפני שאר בעלי הדירות בבית. גם בכך יש לטענת הנתבע 1 כדי להעיד כי הפרויקט נוהל בחוסר שוויון ובחוסר תום לב. לאחר שבחנתי את העדויות שבפני התרשמתי כי המדובר במשא ומתן שהתנהל ביחס לגריעת שטח מדירתם של הנתבעים 1 ו-2 לצורך התקנת פיר המעלית, משא ומתן שכאמור לא צלח, ותחתיו נגרע שטח אחר לטובת המעלית. ראה עדותו של הנתבע 1, פרוטוקול מיום 13.1.13, עמ' 29, שורות 31-40:

"היה לנו מו"מ והוא (היזם א.ש.) ביקש שהוא רוצה להיכנס לדירה שלי כדי שהוא יוכל לצאת לדרך, ואז שאלתי מה הוא מוכן להציע לי ואז אייל ברקוביץ אמר לי שהוא מוכן לפצות אותי במאתיים אלף שקל ואמרתי לו שזה לא מספיק לי כי אני חושב שמגיע לי יותר והוא אמר לי אל תשכח שהדירה שלך עולה בעשרים אחוז לאחר השיפוץ, ואז אמרתי שאני מוכן ללכת לשמאי שיקבע מה שווי הדירה לאחר השיפוץ בבניין ויעשה השוואות מחירים עם הדירה למעלה (הדירה החדשה שתבנה בעקבות הפרויקט. א.ש.) (וסכום שייקבע בינינו של הפיצוי ואני אוסיף לו את השאר כדי לרכוש את דירת הפנטהאוז ש. דובר שתחליפו את הדירות בין הפנטהאוז לבין הדירה שלך ת. כן".

וגם פרוטוקול מיום 13.1.13, עמ' 30, שורות 4-8: "ש. כמה אתה חושב ששווה המטר שרצו לגרוע ממך מהדירה ת. מה אכפת לי אני יושבתי איתו למו"מ וזה מה שהיה ש. בעצם עבור הגריעה של אותו חלק של הדירה שלך הביאה אתכם למו"מ שדרשת מאות אלפי שקלים פיצוי ת. תקרא לזה איך שאתה רוצה, אני אמרתי כסף, לא הזכרתי סכום של כסף.

36. כפי שקבעתי לעיל, אין כל מניעה כי ינוהל משא ומתן בין יזם ובין בעל דירה בקשר למתן תמורה נוספת חלף שטח שנלקח מדירתו, ואין בכך משום פגיעה בעיקרון השוויון או להעיד על חוסר תום לב.

37. טענה נוספת שהועלתה על ידי הנתבעים היא כי הסכמתו של התובע 3 לפרויקט, לאחר שהתנגד לו נחרצות, מעידה כי קיבל תמורה עודפת מהיזם. הנתבעים תומכים טענתם זו בתמליל שיחה שנערך בין הנתבעים 1 ו-2 והתובע 3. בתמליל מתברר התובע 3 בפני הנתבעים ומספר כי הוצע לו לקבל מהיזם פיצוי תמורת הסרת התנגדותו. בתמליל לא צוין מהו אותו פיצוי. הלכה למעשה, התובעים אינם מכחישים כי התובע 3 קיבל תמורה נוספת, מעבר לתמורה אותה קיבלו שאר בעלי הדירות בבית, והיא חניה מקורה (על משמעותה נדון בהמשך). הן מר בן נעים והן מר אמסילי חבר הנציגות הצהירו בתצהירם כי התוכנית מאפשרת הקמת מספר חניות מקורות, ומאחר ומספר החניות המקורות קטן ממספר הדירות בבית הוחלט ע"י נציגות הבית ובאסיפת בעלי הדירות בבית כי חניה מקורה אחת תוקצה לתובע 3 ושאר החניות המקורות תוגרלנה בהגרלה בין בעלי הדירות בבית (ראה סעיף 20 לתצהירו של מר בן נעים וסעיף 22 לתצהירו של מר אמסילי מטעם נציגות הבית), וכן החלטת אסיפת בעלי הדירות מיום 7.12.11 (מוצג נ'4):



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 78/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

"החניות המקורות החדשות שנוצרו יחולקו על ידי הדיירים הקיימים. כאשר חניה מקורה אחת תוקצה לדירת סטבסקי (התובע 3, א.ש.) בתמורה להסכמתו לתוכנית הבנייה ושאר החניות יוקצו על ידי הגרלה הוגנת".

38. לא הוכח כי התובע 3 קיבל תמורה נוספת מעבר לחניה המקורה, וגם לא הוכח כי בעלי דירות אחרים קיבלו תמורה נוספת מעבר לתמורה בגין שטחים שתרמו מדירתם לשם בניית פיר המעלית. בחקירתו הנגדית אישר הנתבע 1 כי אין בידו כל הוכחה כי בעלי דירות נוספים קיבלו תמורה עודפת, וכי הוא מסתמך על דעתו האישית, ראה פרוטוקול מיום 13.1.13, עמ' 30 שורה 20: "לפי דעתי יש עוד כמה דיירים שחוץ מסטבסקי (תובע 3, א.ש.) קיבלו עוד". לא מצאתי, אפוא, כי הוכחה הטענה למתן טובות הנאה למקצת בעלי הדירות בבית באופן הפוגע בשוויוניות.

39. נותר אם כן לבחון האם בהקצאת החניה המקורה לתובע 3 יש כדי לפגוע בשוויון?

40. כפי שצוין לעיל, בהתאם לנסח הרישום של הבית, לכל אחת מהדירות הקיימות צמודה חניה ובסך הכל בבית 14 חניות צמודות. התוכנית מדגימה 20 חניות, מקצתן מקורות. השוואת תשריט הבית המשותף לתוכנית מלמד כי מיקומן של 12 חניות מתוך 14 החניות הצמודות השתנה, וחניות אלו הועתקו ממיקומן המופיע בתשריט רישום הבית המשותף. מיקומן של שתי חניות, האחת מהן צמודה לדירת הנתבעים 1 ו-2, לא השתנה והוא כפי המודגם בתשריט הבית (חניית הנתבעים מסומנת באות א' בתשריט הבית). הנתבעים 1 ו-2 גם לא טענו בעניין זה אחרת.

41. בנסיבות בהן לא נעשה כל שינוי בחניה הצמודה לדירת הנתבעים 1 ו-2, וגם לא נטען על דם כי הם מבקשים להם חניה אחרת, לא מצאתי כי לנתבעים 1 ו-2 הזכות להתנגד לאופן חלוקת החניות הנוותרות. ודוק, לו היו הנתבעים 1 ו-2 מבקשים להיכנס למכסת החניות המקורות המחולקות בין בעלי הדירות, והיו טוענים כי בעצם הבטחת חניה מקורה ספציפית לתובע 3 יש כדי להקנות לו יתרון בלתי הוגן על פניהם (מאחר ובאופן זה קטנה כמות החניות המקורות המוגרלות בין בעל הדירות), יכול והייתי מוצאת ממש בטענתם זו. אך מקום בו הנתבעים 1 ו-2 אינם מגלים כל עניין בקבלת אחת מהחניות המקורות והחניה שבעלותם אינה משתנה על ידי התוכנית מושא התביעה, לא מצאתי לאפשר להם להתערב באופן חלוקת יתר החניות, לרבות המקורות, בין בעלי הדירות בבית. ויוטעם, ברי כי בעל דירה אשר נגרעת ממנו חנייתו הצמודה לו, צריך להסכים לאופן חלוקת החניות החדשות, מה שאין כן לגבי מי שחנייתו נותרה על מכונו, וגם אינו מבקש להחליפה בחנייה מקורה, אין זה סביר כי הלה יתערב באופן חלוקת החניות בין בעלי הדירות אשר חנייתיהם בוטלו ע"י התוכנית החדשה מקום שלא מתקיימת כל פגיעה בו.

42. נוכח כל האמור לעיל, אני דוחה את טענות הנתבעים לחוסר שוויון וחוסר תום לב.

חדר אשפה

43. טענה נוספת שהועלתה ע"י הנתבע 3 היא כי התוכנית משנה את מיקום חדר האשפה, כך שבתוכנית ממוקם חדר האשפה מתחת לסלון ומתחת לחדר השינה בדירתו דבר שיפגע באיכות החיים בשל ריחות רעים, רעשי, יתושים ומקקים. לא מצאתי לקבל טענה זו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 78/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

נראה לי שבמקרה דנן "הפיחות" בזכותו הקניינית של הנתבע 3, הגם שלא הוכחה, בטלה בשישים לעומת ההנאה שתצמח לו מעבודות החיזוק שיעשו בבית. נראה כי ניתן להתגבר על ה"מכשול", ככל שזה יתקיים, בעזרת אמצעים מתאימים לכך.

תשלומי איזון

44. טענה נוספת שהועלתה ע"י הנתבעים 1 ו- 2 היא כי מאחר ועיקר התמורה מתבטאת בשדרוג ערך הדירות בקומות העליונות שקיבלו תוספת של מעלית אשר אינה מקנה יתרון לדירת הנתבעים 1 ו- 2 המצויה בקומה הראשונה, יש צורך בעריכת טבלת איזון בטרם תאושר התוכנית. הנתבעים מפנים לחוות דעת שמאית בה אמדה השמאית את הפרשי השווי בערך הדירות בקומה א' בה מצויה דירת הנתבעים לעומת הפרשי השווי בדירות הממוקמות לדירות העליונות בסך של כ- 300,000 ₪.

45. המחוקק הבחין בין תביעה בהתאם להוראת סעיף 5 לחוק החיזוק בה תובעים רוב בעלי הזכויות את המיעוט המתנגד לבין תביעה בהתאם להוראת סעיף 6 לחוק החיזוק, שבה בעל דירה המתנגד להחלטה מגיש תביעה נגד בעלי הדירות שקבלו החלטה לבצע פרויקט תמ"א 38. משכך, טענה לפיצוי כאמור יש להעלות במסגרת תביעה עצמאית בהתאם לסעיף 6 לחוק החיזוק, ואין היא מהווה טענת הגנה.

לסיכום

46. נוכח כל האמור לעיל, אני דוחה את טענת הנתבעים לחוסר שוויון והעדר תום לב, ושאר טענותיהם, כמפורט לעיל. אני מוצאת כי יש בביצוע העבודות בהתאם לתכנית משום פגיעה בזכותו הקניינית של נתבע 3 בעטיה של החלפת החניה הצמודה לדירתו באחרת, ללא שניתנה לכך הסכמתו. משכך, לא ניתן לאשר ביצוע העבודות בהתאם לתוכנית, כפי שהיא מוגשת בפני כיום, ואני מורה על דחיית התביעה.

47. התובעים ישלמו לגבי רובינשטיין סך של 3,500 ₪ בעבור הוצאות ההליך. מאחר וכל טענות הנתבעים 1 ו- 2, נדחו לא מצאתי לחייב התובעים בתשלום הוצאות נתבעים אלו.

48. אין בקביעתי זו כדי לשלול מהתובעים לפעול להגשת תכנית מתוקנת אשר תדגים מקלט התואם לדרישות הג"א ותכיל תכנית חניות חדשה אשר לא יהיה בה כדי לשנות את מיקומה של החניה הצמודה לדירת הנתבע 3. ככל שלא תינתן הסכמת הנתבעים לביצוע העבודות בהתאם לתוכנית המתוקנת אזי שמורה להם הזכות לשוב ולהגיש תביעה בפני המפקח על רישום מקרקעין בהתאם לחוק החיזוק.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, ג' כסלו, 6 בנובמבר, 2013.

אסתי שחל

מפקחת על רישום מקרקעין, נתניה